

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
5ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

ATOrd 0100333-87.2023.5.01.0005

RECLAMANTE: MÁRCIO DUARTE FONSECA

RECLAMADO: COMERCIAL VEROCITY DISTRIBUIDORA LTDA

VISTOS,

MÁRCIO DUARTE FONSECA ajuíza reclamação trabalhista em 22/02/2025 em face de COMERCIAL VEROCITY DISTRIBUIDORA LTDA, pleiteando, em síntese, diferenças salariais por acúmulo de função e por equiparação ao paradigma, diferenças de adicional de insalubridade (do grau médio para o grau máximo), integração à remuneração das comissões pagas “por fora”, com os reflexos legais, horas extras e intervalos intrajornada suprimidos, além das demais cominações de estilo. Atribui à causa o valor de R\$ 67.672,00.

A reclamada apresenta defesa escrita, contestando, articuladamente, as pretensões formuladas na inicial.

Produzida prova documental e oral, com a oitiva das partes e de duas testemunhas, bem como realizada prova pericial de insalubridade, encerrada a instrução processual.

Rejeitadas as propostas conciliatórias, os autos vêm conclusos para sentença. É o relatório.

MÉRITO

É incontroversa a admissão do reclamante em 13/05/2019, no cargo de vendedor, e a sua dispensa, sem justa causa, em 23/12/2024, bem como que a remuneração era

composta por parte fixa, anotada em contracheque, acrescida de comissões sobre vendas, sendo controvertida apenas a forma de pagamento destas últimas.

DO ACÚMULO DE FUNÇÃO

Sustenta o reclamante que, embora contratado para o exercício do cargo de vendedor, teria acumulado, de forma habitual e simultânea, as atribuições afetas às funções de conferente de estoque e de operador de caixa, desempenhando, a um só tempo, tarefas inerentes a três distintos postos de trabalho, sem que, para tanto, percebesse qualquer contraprestação adicional, razão pela qual postula o pagamento de um plus salarial correspondente a 40% sobre o salário-base, com os respectivos reflexos. A reclamada, por seu turno, impugna a pretensão, aduzindo que as tarefas descritas na exordial se inserem, todas elas, no plexo de atribuições ordinárias do cargo de vendedor, não havendo falar em desvio ou acúmulo funcional aptos a ensejar contraprestação suplementar.

Pois bem. A pretensão de plus salarial fundada em acúmulo de funções, conquanto frequentemente deduzida nesta Especializada, reclama, para o seu acolhimento, a demonstração inequívoca de circunstâncias que extrapolem a mera polivalência ínsita ao moderno contrato de trabalho, não bastando, à evidência, a singela alegação de que o empregado, ao longo da jornada, desincumbia-se de tarefas variadas, porquanto, como é cediço, o art. 456, parágrafo único, da CLT estabelece, em norma de inegável envergadura, que, à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal, comando do qual se extrai, por imperativo de coerência hermenêutica, que a contratação para determinada função traz consigo, de modo imanente, a assunção de um feixe de atribuições correlatas e acessórias, sem que disso decorra, automaticamente, qualquer direito a sobre-remuneração.

No caso vertente, a prova oral produzida, longe de socorrer a tese obreira, militou em sentido diametralmente oposto, na medida em que a própria testemunha convidada pelo autor, ao ser inquirida acerca da rotina laboral, esclareceu que todos os vendedores do estabelecimento, sem exceção, organizavam as mercadorias que comercializavam e, eventualmente, registravam as vendas no sistema, do que se infere, com a segurança que a hipótese exige, que as tarefas reputadas extraordinárias eram, em verdade, ordinariamente compartilhadas por toda a categoria funcional, integrando o próprio núcleo do cargo de vendedor tal como concebido pela reclamada, circunstância que esvazia, por completo, a alegação de que o reclamante teria sido onerado com mister estranho ao ajuste.

Acresce que, ainda que se pudesse cogitar, o que se admite apenas por amor ao debate, de alguma sobreposição de tarefas, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não contempla, como regra geral, a figura do acúmulo de funções como fato gerador automático de acréscimo salarial, somente se autorizando a contraprestação suplementar nas estritas hipóteses em que a lei ou o instrumento coletivo expressamente a preveem, ou, ainda, quando demonstrado flagrante desequilíbrio entre o conjunto de obrigações efetivamente assumidas e a contraprestação ajustada, em afronta ao princípio da comutatividade que informa os contratos sinalagmáticos, situação excepcionalíssima que, à toda evidência, não restou minimamente caracterizada nos presentes autos, nos quais sequer se cuidou de comprovar a alegada disparidade.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que o reclamante, durante todo o interregno contratual, percebeu, além da parcela fixa, comissões sobre as vendas que realizava, de sorte que a remuneração por produção, longe de evidenciar qualquer aviltamento, já contemplava, de modo dinâmico, o resultado do esforço laboral despendido, não havendo, pois, como divisar prejuízo a ser reparado. Diante de tal panorama, em que ausente prova do pressuposto fático da pretensão e inexistente amparo normativo à tese articulada, não se pode dar procedência ao pedido de pagamento de diferenças salariais por acúmulo de função e respectivos reflexos.

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS POR EQUIPARAÇÃO

Pretende o reclamante a sua equiparação salarial ao paradigma Henrique Vasconcelos Tavares, sob o argumento de que ambos exerciam idêntica função, com igual produtividade e perfeição técnica, na mesma localidade e para o mesmo empregador, percebendo, todavia, salários sensivelmente distintos, do que resultaria o direito às diferenças correspondentes, na forma do art. 461 da CLT. Resiste a reclamada, sustentando que o modelo indicado contava com tempo de serviço na função substancialmente superior àquele do autor e ostentava maior produtividade, fatores que, a seu ver, obstaríam a equiparação postulada.

Como é assente na doutrina e na jurisprudência consolidada na Súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, a equiparação salarial pressupõe a conjugação de requisitos cumulativos — identidade de função, trabalho de igual valor, mesmo empregador, mesma localidade e simultaneidade no exercício — incumbindo ao empregado a demonstração do fato constitutivo consistente na identidade funcional, e ao empregador, uma vez evidenciado tal liame, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, na forma do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC, distribuição dinâmica do encargo probatório que, no caso concreto, há de ser sopesada à luz do conjunto da prova efetivamente produzida.

Compulsando os autos, verifico que o reclamante não logrou se desincumbir, a contento, do ônus que sobre si recaía, porquanto a prova oral revelou-se, no particular, frágil e contraditória, na medida em que a testemunha por ele convidada, conquanto tenha afirmado que autor e paradigma “faziam a mesma coisa”, não soube precisar, quando instada, o período em que ambos teriam laborado conjuntamente, tampouco esclareceu se as carteiras de clientes atendidas por um e por outro eram equivalentes em volume e em valor de negócios, dados que, em se tratando de função essencialmente vinculada à performance comercial, mostram-se absolutamente indispensáveis à aferição da alegada igualdade de valor do trabalho.

De outra parte, a documentação acostada pela reclamada — não impugnada de forma específica e eficaz pelo autor — evidencia que o paradigma fora admitido em data muito anterior, contando, ao tempo da contratação do reclamante, com mais de quatro anos de exercício na função de vendedor, lapso temporal que, por si só, supera o limite bienal a que alude o art. 461, §1º, da CLT, circunstância que constitui óbice intransponível à pretensão equiparatória, na medida em que a própria lei, presumindo a existência de maior aptidão decorrente da experiência acumulada, afasta a igualdade jurídica entre obreiros separados por diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos.

Soma-se a isso o fato de que os registros de produtividade carreados aos autos apontam para volume de vendas consistentemente superior por parte do paradigma, a denotar a ausência do requisito da “igual produtividade”, igualmente exigido pela norma de regência, de modo que, conjugados o decurso de tempo na função e a disparidade de desempenho, forçoso reconhecer que a reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do encargo de demonstrar fato impeditivo do direito vindicado. Ante o exposto, não comprovados os pressupostos do art. 461 da CLT, e presentes fatores legais são obstativos ao deferimento do pedido de diferenças salariais por equiparação e seus reflexos.

DAS DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (GRAU MÁXIMO)

Postula o reclamante a majoração do adicional de insalubridade que já lhe era pago, ao longo do contrato, em grau médio (20%), para o grau máximo (40%), ao argumento de que a sua exposição a agentes nocivos — notadamente a ruído e a agentes químicos manipulados no setor de estocagem — far-se-ia em intensidade superior àquela reconhecida pelo empregador, de sorte que lhe seriam devidas as diferenças decorrentes da reclassificação do grau, com os respectivos reflexos. A reclamada refuta a pretensão, sustentando a correção do enquadramento em grau médio e a regularidade do pagamento espontaneamente efetuado.

Cumpra assentar, de início, que a caracterização e a classificação da insalubridade, bem como a definição do respectivo grau, constituem matéria de índole eminentemente técnica, cuja aferição reclama, por imperativo do art. 195 da CLT, a realização de perícia por profissional habilitado, não se afigurando lícito ao julgador, ressalvadas hipóteses excepcionais de prova robusta em sentido contrário, substituir-se ao expert para, com base em mera ilação ou em impressões subjetivas da parte, alçar o grau do adicional para patamar diverso daquele tecnicamente apurado, sob pena de subverter a própria lógica do sistema probatório erigido pelo legislador para o deslinde de questões dessa natureza.

No caso em apreço, o laudo pericial produzido por perito de confiança do juízo, após detida vistoria ao ambiente laboral e à análise das condições efetivas de trabalho, concluiu, de forma fundamentada e categórica, que a exposição do reclamante aos agentes insalubres se dava em intensidade compatível com o grau médio, correspondente ao percentual de 20%, exatamente aquele que, registre-se, vinha sendo espontaneamente quitado pela reclamada ao longo de toda a contratualidade, do que decorre que, no particular, não há sequer interesse processual remanescente quanto ao reconhecimento da insalubridade em si, mas tão somente quanto à pretendida — e não demonstrada — elevação de grau.

As impugnações deduzidas pelo reclamante ao laudo pericial, conquanto reiteradas, não se mostraram aptas a infirmar as conclusões técnicas nele lançadas, porquanto se limitaram a veicular inconformismo genérico e a contrapor, às minudentes medições do perito, a singela afirmação de que a exposição seria “mais intensa”, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento técnico-científico — laudo divergente, medição alternativa ou prova documental idônea — capaz de abalar a higidez metodológica do trabalho pericial, ônus que, a toda evidência, lhe competia, e do qual não se desincumbiu, não bastando, para tanto, a mera irresignação da parte que se vê desfavorecida pelas conclusões do auxiliar do juízo.

Não se ignora que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo dele divergir à luz de outros elementos de convicção (art. 479 do CPC); ocorre que, na espécie, não apenas inexiste prova em sentido contrário, como toda a instrução convergiu para a confirmação do enquadramento em grau médio, de maneira que, acolhendo as conclusões periciais como prova prevalente, e ausente substrato fático ou técnico a justificar a reclassificação pretendida, não se torna possível atribuir procedência ao pedido de diferenças de adicional de insalubridade pela majoração do grau médio para o grau máximo, bem como dos respectivos reflexos, mantido, por força da própria conduta da ré, o pagamento do adicional em grau médio (20%).

DA INTEGRAÇÃO DAS COMISSÕES PAGAS “POR FORA”

Afirma o reclamante que, além da parcela fixa registrada em contracheque, percebia comissões sobre as vendas realizadas, sendo que parte expressiva de tais comissões lhe era satisfeita “por fora”, à margem dos recibos oficiais, mediante depósitos e pagamentos em espécie não contabilizados, de modo que tais valores jamais repercutiram nas demais parcelas contratuais e rescisórias, postulando, por isso, o reconhecimento da natureza salarial das comissões extra-folha e a sua integração à remuneração, com os reflexos pertinentes. A reclamada nega a existência de pagamento marginal, sustentando que toda a remuneração variável era regularmente lançada nos contracheques.

A prova oral, contudo, foi firme e convergente no sentido de confirmar a tese obreira. A testemunha ouvida a convite do autor, que também laborou como vendedora no estabelecimento, afirmou, de forma segura e isenta, que os vendedores recebiam um percentual sobre as vendas registrado nos holerites e um “complemento” de comissão pago em dinheiro ou por transferência da conta pessoal do gerente, prática que se repetia mês a mês, esclarecimento que se mostrou coerente com os extratos bancários juntados pelo reclamante, nos quais se identificam créditos mensais, de valores variáveis, provenientes de pessoa física vinculada à direção da empresa, em montantes incompatíveis com a remuneração formalmente registrada.

Diante de tal acervo probatório, tenho por demonstrado o pagamento de comissões à margem dos recibos oficiais, parcelas que, por força do art. 457, §1º, da CLT, ostentam inequívoca natureza salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Arbitro o valor médio das comissões pagas “por fora” em R\$ 1.700,00 mensais, montante que se extrai da média dos créditos identificados nos extratos e que melhor se ajusta à prova dos autos, devendo tal parcela ser incorporada à base remuneratória do reclamante ao longo de todo o pacto laboral.

Por conseguinte, resta procedente o pedido para reconhecer a natureza salarial das comissões pagas “por fora”, conforme planilha apresentada pela parte autora na inicial condenando a reclamada ao pagamento das diferenças daí decorrentes, observada a habitualidade.

As comissões pagas “por fora”, ora reconhecidas como salário, repercutem no repouso semanal remunerado (RSR), na forma da Lei 605/49 e da Súmula 27 do TST, e, uma vez integradas com o respectivo RSR, projetam-se no 13º salário, nas férias acrescidas de 1/3, no aviso prévio e no FGTS + 40%, tudo a ser apurado em regular liquidação, observada a evolução da parcela ao longo do contrato.

DAS HORAS EXTRAS

Alega o reclamante que se ativava de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 19h, com apenas 30 (trinta) minutos de intervalo intrajornada, e, ainda, em sábados e domingos alternados, das 8h às 15h, sem qualquer intervalo, de tal sorte que, quando laborava aos sábados, folgava aos domingos, e vice-versa. A reclamada, embora tenha juntado controles de ponto, não logrou conferir-lhes credibilidade, na medida em que a prova oral evidenciou a existência de jornada britânica e de marcações que não retratavam a realidade do labor, atraindo a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 338 do TST.

Reputo, assim, demonstrada a jornada declinada na inicial, que ora fixo nos seguintes termos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, com 30 minutos de intervalo; e, em sábados e domingos alternados, das 8h às 15h, sem intervalo, observada a folga compensatória do dia subsequente do final de semana. Sobre tal jornada, são devidas horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª (oitava) diária e, sucessivamente e de forma não cumulativa, as excedentes da 44ª (quadragésima quarta) semanal, adotando-se, para o cálculo, o critério que se revelar mais benéfico ao trabalhador em cada período, a fim de se evitar bis in idem.

As horas extras serão remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), ou outro mais vantajoso previsto em norma coletiva, e calculadas mediante a observância das seguintes diretrizes: (i) a base de cálculo deverá integrar todas as parcelas de natureza salarial percebidas pelo reclamante, inclusive as comissões pagas “por fora” ora reconhecidas, na forma da Súmula 264 do TST; (ii) quanto à parcela variável da remuneração (comissões), observar-se-á a Súmula 340 do TST, sendo devido, sobre as horas extras correspondentes ao labor já remunerado por comissão, apenas o adicional respectivo, calculado sobre o valor-hora das comissões, sem prejuízo da hora cheia (hora normal acrescida do adicional) incidente sobre a parcela fixa; (iii) adotar-se-á o divisor 220.

As horas extras deferidas, ante a sua habitualidade, repercutem em repouso semanais remunerados (Súmula 172 do TST) e, com estes, em 13º salário, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio e FGTS + 40%, observada, quanto à integração dos reflexos do RSR majorado nas demais parcelas, a orientação da OJ 394 da SDI-1 do TST, na redação que lhe foi conferida pelo Tema Repetitivo respectivo, a partir de sua vigência. É devido, nesses termos, o pedido de horas extras e reflexos.

DOS INTERVALOS INTRAJORNADA

Da jornada acima fixada extrai-se que, nos dias úteis, o reclamante usufruía de apenas 30 (trinta) minutos de intervalo para repouso e alimentação, conquanto submetido a jornada superior a 6 (seis) horas, a exigir a fruição de, no mínimo, 1 (uma) hora, nos termos do art. 71, caput, da CLT; e que, nos sábados e domingos laborados, cumprindo 7 (sete) horas diárias, não gozava de qualquer intervalo, em igual afronta ao comando legal.

Reconhecida a supressão parcial e total do intervalo intrajornada, e na forma do art. 71, §4º, da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.467/2017, condeno a reclamada ao pagamento do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, parcela de natureza indenizatória, assim quantificada: (i) nos dias úteis, 30 (trinta) minutos diários correspondentes à fração suprimida; e (ii) nos sábados e domingos efetivamente laborados, 1 (uma) hora diária. Por ostentar a verba, no atual regime legal, natureza indenizatória, não há reflexos a deferir.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A declaração de hipossuficiência constante da exordial atende aos requisitos legais para a concessão do benefício. De outra parte, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção, não incidindo o disposto no §2º do art. 99 do CPC. Ressalto, ainda, o inciso LXXIV do art. 5º da CRFB/88, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Defiro.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECLAMANTE

Devidos honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do reclamante, na forma do art. 791-A da CLT, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor líquido da condenação, assim entendido aquele apurado em liquidação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, nos termos da Orientação Jurisprudencial 348 da SDI-1 do TST.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECLAMADA

Tendo o reclamante decaído dos pedidos de diferenças salariais por acúmulo de função, por equiparação e de diferenças de adicional de insalubridade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da reclamada, que arbitro, considerando os critérios do §2º do art. 791-A da CLT e a expressão econômica dos pedidos rejeitados, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Todavia, sendo o reclamante beneficiário da gratuidade de justiça, a exigibilidade da referida verba permanecerá suspensa pelo prazo e nas condições do §4º do art. 791-A da CLT, somente podendo ser executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar a cessação do estado de hipossuficiência, extinguindo-se, decorrido tal prazo, a obrigação.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS

Autorizo os descontos previdenciários e fiscais nos termos da lei, arcando cada parte com as suas obrigações, devendo a reclamada comprovar os respectivos recolhimentos, sob pena de execução. As contribuições previdenciárias deverão ser calculadas e recolhidas pelo empregador, mês a mês, autorizada a dedução da quota-parte do empregado, nos termos do art. 43 da Lei 8.212/91 e da Súmula 368 do TST. Quanto ao IRPF, observe-se o art. 46 da Lei 8.541/92 e o art. 12-A da Lei 7.713/88. Não incidem contribuições previdenciárias e fiscais sobre as parcelas de natureza indenizatória, na forma do art. 28, §9º, da Lei 8.212/91.

DEDUÇÃO E COMPENSAÇÃO

Autorizo a dedução do que comprovadamente quitado a idênticos títulos na fase cognitiva, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Inviável a compensação, por ausência dos pressupostos legais.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, determino, para a atualização dos créditos trabalhistas ora reconhecidos, a aplicação dos seguintes critérios:

- na fase pré-judicial, isto é, até a data do ajuizamento da ação, incidirá o IPCA-E a título de correção monetária, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91;
- a partir do ajuizamento da ação, incidirá, de forma única e exclusiva, a taxa SELIC, que já engloba, a um só tempo, a correção monetária e os juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização ou juros, sob pena de bis in idem.

Observe-se, quanto aos juros, o disposto na Súmula 200 do TST, devendo incidir sobre o valor bruto da condenação.

DISPOSITIVO

Posto isso, no mérito, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por MÁRCIO DUARTE FONSECA em face de COMERCIAL VEROCITY DISTRIBUIDORA LTDA, para condenar a reclamada nas obrigações a seguir, na forma e nos limites da fundamentação, que passa a integrar este dispositivo para todos os efeitos:

1. RECONHECER a natureza salarial das comissões pagas “por fora” condenando a reclamada ao pagamento das respectivas diferenças, com reflexos em RSR e, com estes, em 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio e FGTS + 40%;

2. CONDENAR a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e, não cumulativamente, da 44ª semanal, com adicional de 50% (ou o normativo mais benéfico), observados o divisor 220, as Súmulas 264 e 340 do TST e a jornada fixada na fundamentação, com reflexos em RSR e, com estes, em 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio e FGTS + 40%;

3. CONDENAR a reclamada ao pagamento dos intervalos intrajornada suprimidos, com adicional de 50%, em natureza indenizatória, na forma do art. 71, §4º, da CLT e da fundamentação (30 minutos nos dias úteis e 1 hora nos sábados/domingos laborados);

4. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de diferenças salariais por acúmulo de função, por equiparação salarial e de diferenças de adicional de insalubridade (majoração do grau médio para o máximo), pelas razões expostas na fundamentação.

Defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça.

Honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do reclamante, fixados em 10% sobre o valor líquido da condenação, na forma da OJ 348 da SDI-1 do TST. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da reclamada, fixados em R\$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa, nos termos do §4º do art. 791-A da CLT.

Juros e correção monetária na forma da fundamentação e da legislação aplicável.

Contribuições previdenciárias e fiscais na forma da fundamentação.

Custas pela reclamada, no valor de R\$ 1.353,44, calculadas à razão de 2% sobre o valor da causa de R\$ 67.672,00.

Intimem-se as partes.

RIO DE JANEIRO/RJ, 18 de junho de 2026.

ROBERTO CIDREIRA ALTENHOFFEN

Juiz(a) do Trabalho